

1502309-05.2021.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Favorecimento real
Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues
Comarca: Franco da Rocha
Foro: Foro de Franco da Rocha
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/07/2022
... de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franco da Rocha
Foro de Franco da Rocha
Vara Criminal
Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502309-05.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502309-05.2021.8.26.0544
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Favorecimento real
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263895/2021 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 20508547 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3072/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2263895 - DEL.POL.FRANCO ROCHA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALMIR JOSE DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

ALMIR JOSÉ DA SILVA foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 349-A, do Código Penal, na forma do art. 70, do Código Penal, pois, segundo denúncia, no dia 20 de setembro de 2021, pela manhã, nas dependências da Penitenciária situada na Estrada do Governo, Fazenda Belém, em Franco da Rocha, trazia consigo, no interior de seu estômago, para fins de entrega a terceiros, 40 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 270g de massa bruta e 40 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 294g;

substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, trazia consigo no interior de seu estômago, 02 telefones celulares, 01 carregador de celular e 01 placa de celular.

Recebida a denúncia (fls. 86), o réu foi citado (fls. 105) e apresentou defesa prévia (fls.108/109).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e realizou-se o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, inexigibilidade de conduta diversa, atipicidade do crime previsto no art. 349-A do CP e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima.

É o relatório

Passo a decidir.

No mérito, o pedido condenatório é procedente

A materialidade dos crimes vem demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de exibição de apreensão (fls. 09/10), relatório de ocorrência de fls. 68/75, laudo toxicológico definitivo de fls. 137/139 e laudo de objetos de fls.153/154

A autoria é certa.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, disse que os fatos são verdadeiros. Disse que ingeriu os objetos por ter uma dívida de drogas no interior do presídio. Foi procurado pelos criminosos que disseram que engolissem os objetos. Ingeriu maconha, cocaína e os celulares. Recebeu um pacote fechado com tudo dentro. Engoliu os objetos individualmente. Sabia o que estava engolindo.

A versão apresentada pelo acusado se encontra em consonância parcial com o cenário probatório obtido.

Carlos Eduardo Marciano disse que é policial penal e, no dia dos fatos, era retorno da saída temporária. Ao passar pelo scanner o réu foi surpreendido com objeto estranho em seu organismo. Foi encaminhado ao hospital e ele expeliu os objetos após tomar laxantes. Ficou acompanhando o réu no hospital e anotou objetos que foram expelidos, tratando-se de droga e aparelho telefone celular, ao que se recorda.

Edivaldo Rogério D'Aparecida, testemunha, disse que é policial penal, e participou da mesma diligência narrada por seu companheiro. Disse que é o diretor de segurança. Determinou o encaminhamento do réu para a UPA, onde o réu permaneceu por sete dias ao que se recorda. O réu expeliu drogas (maconha e cocaína) dois celulares, uma placa e cabo USB.

Quanto aos agentes de segurança ouvidos, não há indícios de que tinham motivos para acusar o réu de forma leviana e gratuitamente.

Neste diapasão:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial.

Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.”(JTJ 208/273).”“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada em juízo.”(TACrim, 12ª Câmara, rel. Desembargador João Morenghi, Apelação 1473255/5).

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana. A quantidade de droga apreendida, e os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos, levam à certeza de que o acusado guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se pois a sua condenação. Por fim, cabe assinalar que a denúncia imputa ao réu a conduta de “ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente”, e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução. Ainda, há de se mencionar que o fato de ser ou não usuário de entorpecentes, não afasta a situação de traficância e portanto, não há que se falar em desclassificação do delito.

Não há como exigir-se dos agentes prisionais que indiquem, com exatidão, quantos e qual tipo de drogas expelidas por cada agente criminoso. Diversas são as ocorrências de mesma natureza, sendo que o relatório elaborado pelos agentes durante o período em que acompanharam os réus indica com precisão os momentos, quantidades e natureza da droga localizada sendo que, tal constatação, se deu apenas em delegacia de polícia. Não recordar-se de tais detalhes não afasta a clareza do relatado e nem coloca qualquer dúvida que possa vir a favorecer os réus.

O réu admitiu o fato criminoso e disse que o teria feito sob grave ameaça de terceiros. Tal fato não afasta a culpabilidade eis que não há prova concreta das ameaças sofridas já que o teor das ameaças sofridas mostrou-se vago e carente de lastro probatório. Destaco ainda, que o réu deveria ter procurado a autoridade policial competente informando a ameaça sofrida buscando meios de ver-se protegido, o que afasta a indicação de que seria inexigível conduta diversa.

Corriqueiras são as alegações de ameaças em crimes dessa natureza, sendo necessário que esta seja acompanhada de um mínimo de certeza para sua consideração, eis que sequer conseguiu o réu indicar de modo preciso o teor das ameaças sofridas. A mera menção acerca da coação não atesta a sua existência e, muito menos, a sua irresistibilidade, sendo este um ônus probatório da Defesa. Para que haja o reconhecimento da coação moral irresistível, ela deve restar cabalmente demonstrada.

Nesse sentido:

“Quanto à invocada excludente de culpabilidade, não se incumbiu o denunciado de demonstrar, como lhe cabia, que agiu sob coação moral irresistível. Ora, para que possam ser admitidas, as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade devem ficar cabalmente comprovadas, competindo tal ônus ao réu. Por óbvio, não basta apenas

alegá-las. Ademais, indispensável à caracterização da dirimente que a coação seja insuperável, invencível, diante de perigo sério e atual, de tal sorte que o coagido não consiga arrostá-la senão pela prática da infração. E tal não decorre, necessariamente, da alegada condição de devedor de traficante." (STJ, REsp 1711751/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, publicação 14.03.2018)

"Na hipótese vertente, a corré alegou ter agido nos moldes retratados na denúncia, sob o argumento de temor de represálias decorrentes de dívidas contraídas com um traficante. Não basta para se acolher a excludente de culpabilidade a vaga alegação de temor. É necessário a prova de fato concreto, que justificasse a impossibilidade da realização de conduta diversa à do crime. Não se vislumbrando na instrução do processo a ocorrência dessa situação extrema, torna-se inconvincente a tese defensiva." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500388-37.2019.8.26.0558, Rel. Figueiredo Gonçalves, 1ª Câmara Criminal, j. 20/02/2021).

O crime de tráfico se deu no interior de um presídio, conforme relato unânime da prova oral e demais documentos que instruem o feito, devendo incidir a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas .

Quanto ao crime previsto no art. 349-A do CP, restou incontroverso que o réu ingressou com quatro aparelhos celulares, dois carregadores e dois fones de ouvido no centro de detenção. Destaco que o fato dos aparelhos constarem como inoperantes decorrem apenas de não possuírem chip para operação integral.

Promover a entrada de componentes de aparelho telefônico de comunicação, sobretudo placas e chips, já configura o delito em apreço, uma vez que é mais do que sabido que espalhar acessórios e peças de aparelhos celulares em celas diversas, é conduta comum para não ser descoberto.

Se assim não fosse, a cisão do bem em diversas partes e seu envio ou ingresso em estabelecimento prisional jamais encontrariam adequação típica no crime de favorecimento real impróprio, o que causaria impunidade.

No mais, observo que não se trata de crime impossível (art. 17, CP), pois não há absoluta impropriedade do objeto, uma vez que apenas foi constatada a ausência de peças, as quais podem ser repostas a qualquer tempo, não efetivo defeito que impeça o aparelho de funcionar.

Assim, restou inconteste que os objetos apreendidos permitem a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Quanto ao concurso de crimes, entendo que deva ser aplicado o formal próprio, pois, com uma conduta, o agente praticou dois crimes.

No entanto, ante a redação do art. 70, parágrafo único, CP, verifico que, no caso em tela, apesar de, em tese, ser cabível o concurso formal próprio, na prática deve ser utilizado o cúmulo material benéfico. Isso porque, a exasperação da pena do tráfico, mais grave no caso concreto, resultará em reprimenda maior do que a devida ao delito do art. 349-A, CP. Assim, é mais vantajoso que se somem as penas.

Além disso, consigno que a natureza distinta das penas, reclusão e detenção, também impede seja aplicada a exasperação no caso em tela

A condenação, portanto, é medida que se impõe

Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes (0016496-03.2013.8.26.0050. Entendo que a culpabilidade do crime previsto no art. 349-A do CP foi especialmente gravosa. O

réu foi surpreendido de posse de 02 aparelhos, 01 carregador e 01 placa de celular, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta pela quantidade e diversidade de elementos. As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Assim, elevo a pena-base de do crime do art. 349-A do CP em 1/6 e do crime de tráfico em 1/8 restando em:

Art. 33 da lei 11.343/06: 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
art. 349-A do Código Penal: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção

Na segunda fase, verifico presente a atenuante relativa à confissão espontânea. No entanto, o réu alegou ter realizado o fato sob coação moral irresistível, o que a fasta a incidência integral da atenuante. Ainda, ostenta reincidência (0064978-06.2018.8.26.0050) Assim, prevalece a circunstância agravante, razão pela qual elevo as penas em 1/7:

Art. 33 da lei 11.343/06: 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.
art. 349-A do Código Penal: 04 (quatro) meses de detenção

Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei Antidrogas, na medida em que, pelos relatos dos policiais, ficou evidente que o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional e, por isso, tendo este tráfico a especial finalidade de introduzir a droga naquele local, mas por não ter provas de que o entorpecente tenha chegado às mãos de outros presidiários, a pena será aumentada de 1/6. Não há causa de aumento quanto ao crime do art. 349-A do CP. Por ser os acusado reincidente inaplicável a causa de diminuição do §4º do art. 44 da lei 11.343/03. Restam as penas concretas e definitiva em:

Art. 33 da lei 11.343/06: 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa
art. 349-A do Código Penal: 04 (quatro) meses de detenção.

Nos termos dos artigos 49, parágrafo 1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica dos réus, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena de reclusão será cumprida no regime inicial fechado e a de detenção no regime inicial semiaberto, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do que determina o art. 33 do CP.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 349-A, do Código Penal, na forma do art. 70, do Código Penal, às penas de:

Art. 33 da lei 11.343/06: 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa
art. 349-A do Código Penal: 04 (quatro) meses de detenção.

Nego eventual recurso em liberdade, diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, já que o acusado foi condenado a uma pena de mais de sete anos, no regime fechado, de modo que certamente tentaria fugir da pena ora imposta, além de possuir mais antecedentes.

Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Custas na forma da lei, devendo ser a gratuidade apreciada pelo juízo da execução penal.

P.I.C.

Franco da Rocha, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA